

[문제-1]	
I. 설문(1)	
1. 문제의 소재 0.5	
	대표권을 직권으로 조사할 수 있는지, 도급계약에 대해서만 다투
	어지던 중 대표권 흠결을 이유로 소각하함이 적법한지 문제된다.
2. 대표권의 소송법상 의의 2	
(1)	[제64조] 대표자에 대해서 법정대리인에 관한 규정이 준용된다.
(2)	직권조사사항인지 여부
	대표권 존부는 소송요건으로 직권조사사항이므로 사실·증거를 직
	권탐지할 의무는 없어도 대표권에 의심이 들만한 사정이 보인다면 상대방이 다투지 않더라도 심리조사할 의무가 있다.
(3)	흠결시 취급
	[제59조] 대리권 흠결시 법원은 기간을 정해 보정 명하여야 한다.
3. 대표권 흠결로 소각하시 지적의무 행사 요부 2	
(1)	[제136조 4항] 예상외 재판 방지 위해 당사자가 간과했음이 분명한 법률상 사항에 관해 의견진술기회 부여해야 한다.
(2)	判例
	변론종결시까지 대표자 지위에 관해 쟁점이 되지 않은 경우 이에
	관해 의견진술기회 부여 없이 대표권 흠결로 소각하시 예상외 재판으로 석명의무를 다하지 않은 것이다.
4. 사안해결 0.5	
	i) 丙대표권 존부를 직권으로 조사한 것은 타당하나 ii) 도급계약

	에 대해서만 다투어지던 중 丙대표권 흠결을 이유로 보정을 명하거나 의견진술기회 부여 없이 소각하함은 적절하지 않다.
II. 설문(2)	
1. 문제의 소재 1	
	무권대표자 丙이 선임한 소송대리인 戊의 행위에 대해 추인으로 적법해질 수 있는지 검토하고, 아무런 근거 없이 한 시효주장에 대해 법원이 증명 촉구 석명을 해야 하는지 검토한다.
2. 소송대리인 戊에 대한 추인 인정 여부 3.5	
(1) 무권대리행위 소송상 취급	
	무권대리행위는 소송행위 유효요건으로 추인되지 않는 한 무효이며, 소송요건으로 직권조사사항에 해당한다.
(2) 무권대리행위에 대한 추인	
1)추인 의의 및 취지	
	유동적 무효인 소송행위를 소급하여 유효하게 만드는 행위다.
2)추인 요건	
	i)소송행위인바 소송능력, 대리권 요한다. ii)명시적으로도 가능하나 判例는 2심에서 아무런 이의 없이 무권대리에 기초한 1심 소송결과 진술한 경우 묵시적 추인된 것이라고 본다. iii)시기제한 없고 상소심에서도 가능하다. iv)소송행위 전부 추인해야 한다.
(3) 사안	
	i)무권대표자 丙이 선임한 소송대리인 戊의 행위는 무권대리행위가 되며 그의 소송행위는 추인되지 않는 한 유동적 무효이다.

	ii)적법한 대표자 丁이 戊와 출석해 계약유효, 시효완성만 주장하고 무권대리 이의하지 않아 항소심에서도 묵시적 추인 가능하다.
3. 소멸시효 주장에 대한 증명촉구 석명 요부 3.5	
(1) 석명권 의의 및 취지 [제136조 1항]	
	소송관계 분명하게 하기 위해 당사자에게 질문하고 증명을 촉구하는 법원의 권능이다. 변론주의 보완을 위해 인정한다.
(2) 석명 의무의 범위	
1)①석명권의 범위와 석명 의무 범위는 일치하여 석명권 불행사시 상고이유로 보는 견해 ②석명권은 권능이지 의무가 아니므로 상고이유 아니라는 견해 있 ③절충설이 있다.	
2)생각건대 상고심의 과도한 사실인정 간섭 방지, 변론주의 보완 위해 석명권 해태로 심리가 현저히 조잡해지면 상고이유가 된다.	
(3) 증명촉구의 석명	
1)다툼 있는 사실에 증명책임 있는 자가 부주의, 오해로 증거를 대지 못한 경우 법원은 증명촉구 의무를 진다.	
2)判例는 원고가 시효중단을 주장했다면 마땅히 석명권 행사하여 원고에게 증명을 촉구했어야 한다고 한다.	
(4) 사안	
	피고는 18.4.15.자로 시효완성 주장하며 별다른 근거 제시하지 않았고 이는 피고가 증명책임 지는바 법원은 증명촉구의 석명한다.
4. 사안해결 0.5	
	戊의 소송수행은 추인으로 적법하며 법원은 증명촉구의 석명한다.

Ⅲ. 설문(3)	
1. 문제의 소재 0.5	
	피고는 본래와 다른 소멸시효 기산점인 15.6.1.을 주장하고 있는
	바 변론주의 원칙상 법원이 이에 구속되어 판단해야 하는지, 위법
	한 1심 소각하판결 취소시 1심으로 사건 환송해야 하는지 논한다.
2. 변론주의 의의 및 내용 0.5	
	i) 사실, 증거의 수집, 제출책임을 당사자에 맡기고 법원은 당사
	자가 제출한 소송자료만을 재판의 기초로 한다는 원칙이다.
	ii) 주요사실주장책임, 자백의 구속력, 증거제출책임으로 구성된다.
3. 주요사실 주장책임 1	
	자신에게 유리한 주요사실 주장하지 않으면 그 사실은 없는 것으
	로 취급되어 받는 불이익 의미한다. 법원은 당사자가 주장하지 않
	은 사실에 기초하여 판결할 수 없다.
4. 주요사실 판단 2	
(1) 학설 및 判例	
	i) 기준재구성설 있으나 ii) 통설, 判例인 법규기준설은 주요사실
	이란 법률효과 발생시키는 실체법상 구성요건 해당사실이라 한다.
(2) 검토 및 사안	
	i) 생각건대 명확한 기준 제시하는 법규기준설 타당하며 ii) 사안
	에서 소멸시효 항변의 소멸시효 기산점이 주요사실인지 문제된다.
5. 소멸시효 항변에서 기산점이 주요사실인지 여부 3.5	
(1) 判例	

	i) 소멸시효 기산점은 채무소멸이라는 법률효과 발생의 요건에
	해당하는 소멸시효 기간계산의 시발점으로서 소멸시효 항변의 법
	률요건 구성하는 구체적 사실에 해당하여 변론주의 적용대상이다.
	ii) 본래 소멸시효 기산점과 당사자 주장 기산점이 다르면 변론주
	의 원칙상 법원은 당사자 주장 기산점 기준으로 판단해야 한다.
(2)	학설 i) 주요사실설은 소멸시효 기산점은 민법 제166조에 규정된
	바 법규의 직접 요건사실로 주요사실이라고 한다. ii) 간접사실설
	은 기산점을 당사자 주장으로 판단하면 상대방에게 불이익이 가
	해질 수 있어 간접사실이라고 한다.
(3)	검토 및 사안
	i) 생각건대 민법상 규정되어 있는 소멸시효 기산점은 주요사실
	이다. ii) 사안에서 소멸시효 기산점을 15.6.1.로 주장하는 것은
	소멸시효 기간계산 시발점으로 소멸시효 항변의 법률요건 구성하
	는 구체적 사실로 주요사실이며, 법원은 실제 기산점인 15.8.1.과
	다르더라도 이에 기초하여 판단하되, 최종적으로 증거로 나타난
	15.8.1.과 달라 주장대로 기산점을 인정할 순 없을 것이다.
6.	법원의 판결 3.5
(1)	1심판결의 위법성
	i) 대표권 흠결로 소각하시 보정명령 또는 의견진술기회 부여했
	어야 한다. ii) 설령 그런 조치를 취했다고 하더라도 무권대리행위
	는 주인은 소급효가 있는바 무권대리행위는 소급 유효해진다. iii)
	따라서 1심 소각하판결 위법한바 항소심은 이를 취소한다.

(2) 항소심 판결 - 1심 소각하판결 취소하는 경우	
1)제418조 본문 및 단서	
i)소각하 1심판결을 취소하는 경우 항소심은 사건을 1심에 환송해야 한다. ii)다만, 1심에서 본안판결 가능할 정도로 심리되거나	
당사자 동의가 있으면 본안판결 가능하다.	
2)사안	
1심 첫기일에서 도급계약 성부만 다투어졌을 뿐 소멸시효 심리되	
지 않아 본안판결할 정도로 심리되지 않았고 당사자 동의도 없어	
1심 소각하판결 취소시 제418조 본문에 따라 1심으로 환송한다.	
7. 사안해결 0.5	
법원은 소멸시효 기산점 주장에 기초해 판단하되 증거가 없어 인	
정할 수 없고 위법한 1심 소각하판결 취소하여 1심으로 환송한다.	
위 설문(3)의 “항소심의 본안판결”에 대한 내용을 답안으로 적지 않은 이유는 다음과 같음.	
1. “항소심의 본안판결”에 대한 내용을 배점 15점 배점 안에 적을 수 없음. 항소심의 본안판결에 대한 내용을 적으면 논점은 아래와 같은데 이를 모두 적으면 변론주의와 소멸시효 기산점 논의를 포함한 모든 논점을 매우 압축기재해도 최소 20점 정도가 나옴.[논점 추가기재를 원한다면 아래 논점 참조]	
1)본안판결 위해서는 주요사실인 도급계약 및 소멸시효완성 모두 각각 판단해야 함.	
2)도급계약 - 자백 의의취지 및 효과	
3)소멸시효 - 제265조(또는 민법 제168조), 민법 제174조, 두번의 최고 중 소제기로부터 6개월 내인 두번째 최고까지만 시효중단 소급효 인정됨(민법判例), A채권 시효완성됨(청구기각), B채권 시효중단됨(청구인용) + A채권에 대해서는 1심 소각하 원고만 불복시 청구기각 가부(학판검)	
2. “항소심 본안판결”에 대한 내용은 어차피 항소심이 1심 환송판결하는데 굳이 언급하는 것은 부자연스러움. 만약, “항소심 본안판결”에 대한 내용을 언급한다고 하더라도 본안판결 내리기 위해 필요한 위 논점들을 모두 기재한 다음 1심환송을 적어야 하고 일부만 기재하다가 1심환송으로 결론내리는 것은 논리흐름상 부자연스러움.	
다만, 위 “항소심 본안판결”에 대한 내용을 전부는 아니더라도 일부만 어느정도 기재했더라도 논리가 어긋나지만 않았으면 모두 후하게 점수를 받았음. 답안 전개가 여러 방향으로 가능한 점, 배점에 문제 생길 수 있는 점, 기타 논란의 소지가 있던 문제인 점에 비추어 관대한 채점이 이루어짐.	
[출제과정에서 검토위원 요청으로 난이도를 하향 조정한 문제로, 최초 만들어진 문제에서 난이도를 낮추어 수정하다보니 답안 전개 방향이 다양하게 갈릴 수 있는 문제가 된 것으로 보여짐.]	

[문제-2]	
I. 설문(1)	
1. 문제의 소재 0.5	
	乙이 진단서의 丙작성을 다투고 확인서의 구청발급을 다투는바
	서증에서 乙주장 성격 및 문서의 진정성립을 추정·복멸 논한다.
2. 문서의 진정성립 의의 0.5	
	문서가 문서신청자에 의해 작성자로 주장되는 자 의사에 기해 작
	성된 것 말한다. 진정성립 인정된 문서는 형식적 증거력이 있다.
3. 문서의 진정성립 판단 및 증거항변 1	
	(1) 인정, 침묵, 부인, 부지의 인부절차 및 변론전취지에 따라 자유심
	증으로 판단한다.
	(2) 증거항변
	상대방이 신청한 증거의 증거능력 또는 증거력 다투는 주장이다.
4. 사문서의 추정 및 복멸 - 진단서 2.5	
(1) 추정 - 2단의 추정	
	1)[제357조] 제출자는 사문서가 진정한 것임을 증명해야 한다.
	2)判例는 인영의 진정이 인정되면 날인의 진정이 사실상 추정되고,
	날인의 진정이 인정되면 문서 전체의 진정성립이 제358조에 의해
	유사적 추정된다고 하여 2단의 추정을 인정한다.
(2) 복멸	
	1)인영의 진정은 법관이 의심 품게하는 반증으로 복멸시킬 수 있다.
	2)判例는 날인의 진정 및 문서 진정성립 추정은 사실상 추정이므로

	다투는 자가 반증으로 문서 진정성립에 의심을 품게 하는 사정 입증시 추정 깨진다고 한다.
5. 공문서의 추정 및 복멸 - 확인서 1.5	
(1) 추정 [제356조]	
	공무원이 직무상 작성한 문서는 진정성립이 유사적 추정된다.
(2) 복멸	
	공문서 진정성립 유사적 추정은 사실상 추정의 명문화이므로 반증으로 진정성립에 의심을 품게 하는 사정 입증시 깨진다.
6. 사안해결 3	
(1) 乙주장 성격 - 부인 및 증거항변	
	乙은 진단서, 확인서의 진정성립을 부인하여 형식적 증거력 다투는바 소송상 항변으로 증거항변에 해당한다.
(2) 진단서	
	i)진단서는 개인병원장 丙이 작성한 사문서다. ii)甲은 진정성립 증명해야 하지만 2단의 추정을 활용할 수 있다. iii)乙은 인영의 진정, 날인의 진정, 문서 진정성립을 반증으로 복멸시킬 수 있다.
(3) 확인서	
	i)확인서는 구청이 발급해 공문서다. ii)확인서는 진정성립이 유사적 추정된다. iii)乙은 공문서 진정성립을 반증으로 복멸시킨다.
II. 설문(2)	
1. 문제의 소재 0.5	
	진단서와 확인서 모두 형식적 증거력이 인정되는바 문서의 종류

	에 따른 실질적 증거력 판단 방법 검토하여 각 문서에 기초하여 손해배상액을 인용할 수 있는지 논한다.
2. 실질적 증거력 의의 1	
	어떤 문서가 요증사실을 증명하기에 얼마나 유용한가의 증거가치를 말한다. 문서가 실질적 증거력이 있으면 그 내용을 진신한 것으로 인정하여 사실판단 할 수 있다.
3. 실질적 증거력 판단 1	
(1)	인부절차 없이 법관의 자유심증으로 판단한다.
(2)	[제202조] 법원은 변론 전취지와 증거조사 결과 참작하여 자유로운 심증으로 사회정의, 형평 이념에 입각하여 논리와 경험 법칙에 따라 판단한다.
4. 처분문서의 추정 및 복명 0.5	
(1) 처분문서 의의	
	처분문서란 법률행위가 문서 자체에 의해 이루어진 문서이다.
(2) 判例	
i)	처분문서는 형식적 증거력 인정시 실질적 증거력 추정된다.
ii)	처분문서는 성립의 진정 인정되면 기재 내용을 부인할 만한 분명하고도 수긍할 수 있는 반증이 없는 한 처분문서에 기재된 문언대로 의사표시의 존재와 내용을 인정해야 한다.
5. 보고문서의 추정 및 복명 1.5	
(1) 보고문서 의의	
	작성자가 보고 듣고 느낀 경험 또는 사실판단을 기재한 문서이다.

(2) 判例	
	진정성립 추정되는 공문서는 의문점이 있더라도 기재내용과 배치되는 사실이거나 문서 작성경위에 비추어 기재가 비정상적으로 이루어졌거나 내용의 신빙성을 의심할 만한 특별한 사정을 증명할 다른 증거 없다면 기재내용대로 증명력 가진다고 한다.
6. 사안해결 2.5	
(1) 진단서, 확인서는 모두 사실판단을 기재한 보고문서이다.	
(2) 진단서는 사문서인바 법원은 자유심증에 의해 실질적 증거력을 인정하여 기재 내용에 기초한 사실인정 할 수 있다.	
(3) 확인서는 공문서인바 기재내용과 배치되는 사실, 비정상적인 작성 등 특별한 사정이 없다면 그 기재 내용대로 사실인정 할 수 있다.	
(4) 법원은 특별한 사정이 없는한 확인서에 의해 500만 원은 인정할 것이다. 다만, 진단서는 자유심증에 의해 판단하는바 반드시 1500만 원의 치료비가 인정되진 않는다. 따라서, 합산 손해액을 반드시 2000만 원으로 인정해야 하는 것은 아니다.	
[문제-3]	
I. 설문(1)	
1. 문제의 소재 0.5	
	甲의 乙에 대한 등기말소청구의 청구인용판결이 확정된 후에 乙이 전소 판결확정 전에 A토지에 대해 취득시효가 완성되었음을 이유로 甲을 상대로 소유권이전등기청구를 하였는바 전소 기판력

	이 후소에 모순관계로 작용할 수 있는지 문제된다.
2. 기판력의 의의 및 취지 1	
	확정된 중국판결 내용이 후소에 대해 갖는 구속력을 의미한다. 판결모순방지 및 법적 안정성을 위함이다.
3. 기판력 주관적 범위 1	
(1) 상대성원칙	
	전소 절차에 참여할 수 없었던 제3자 보호를 위해 기판력은 전소 당사자 사이에 미치는 것이 원칙이다.
(2) 사안	
	甲과 乙은 전소 당사자인바 전소 기판력 주관적 범위에 해당한다.
4. 기판력 객관적 범위 1	
(1) [제216조 1항] 오판시정 및 신속한 결론을 내리기 위해 기판력은	
	판결 주문 판단에 발생한다.
(2) 사안	
	기판력은 甲의 乙에 대한 등기말소청구권 존재에 발생한다.
5. 기판력 작용국면 해당 여부 4.5	
(1) 작용국면 유형	
	전소 기판력은 후소에 동일, 선결, 모순관계로 작용할 수 있다.
(2) 전소에서 문제된 것과 다른 청구원인에 기한 후소 청구	
1)문제점	
	등기말소청구 패소한 피고가 후소로 소유권이전등기청구하면, 전소와 모순되는 소유권이전등기 판단 구하는 것인지 문제된다.

2)判例	
원인무효에 기한 등기말소청구가 확정되었더라도 그 기판력은 소송물이었던 말소등기청구권 존부에만 미치므로 그 소송에서 패소한 당사자는 전소에서 문제된 것과는 전혀 다른 청구원인에 대하여 상대방에 대해 소유권이전등기청구를 할 수 있다.	
3)학설 i)모순관계 긍정설은 법적 안정성을 중시하여 전후소 소송물은 서로 모순관계에 해당하므로 변론종결 전 시효취득 사실은 차단된다고 한다. ii)모순관계 부정설은 구체적 타당성을 중시하여 등기말소청구의 청구원인과 다른 청구원인을 이유로 이전등기 청구하였기 때문에 모순관계에 해당하지 않고 변론종결 전 시효취득사실은 차단되지 않는다고 한다.	
4)검토 및 사안	
i)생각건대 후소는 전소 판결주문 판단을 다투는 것이라고 할 수 없으므로 전소 기판력에 저촉되지 않는다고 봄이 타당하다.	
ii)사안에서 전소 기판력은 甲의 乙에 대한 등기말소청구권 존재에 발생하므로 전소 패소한 乙은 전소에서 문제된 것과 다른 취득시효완성에 기한 소유권이전등기청구를 제기해도 전소 기판력이 작용하지 않는다.	
6. 기판력 시적범위 및 차단효 1	
(1) 원칙	
i)기판력은 전소 변론종결시 법률관계 판단에 발생한다. ii)전소 변론종결 전 제출가능했던 공격방어방법은 후소에서 차단된다.	

(2) 사안	
甲의 등기말소청구 확정판결 기판력은 전소 변론종결시 기준 법률관계 판단에 발생하나 乙이 후소로 주장하는 취득시효완성은 전소 기판력이 작용하는 부분이 아니므로 차단되지 않는다.	
7. 사안해결 0.5	
乙의 후소는 전소 기판력이 저촉되지 않으므로 이를 배척한 후소 법원의 판결은 부적법하다.	
II. 설문(2)	
1. 문제의 소재 1	
단독상속 원인으로 소유권확인의 소 확정 판결 후 기각된 부분에 대해 재산분할협의 원인으로 소유권확인의 후소 제기시 소송물 동일성, 변론종결 후 사유 존부에 따른 기판력 저촉여부 논한다.	
2. 기판력의 의의 및 취지 1	
확정된 중국판결 내용이 후소에 대해 갖는 구속력을 의미한다. 판결모순방지 및 법적 안정성을 위함이다.	
3. 기판력 주관적 범위 1	
(1) 상대성원칙에 따라 전소 절차에 참여할 수 없었던 제3자 보호를 위해 기판력은 전소 당사자 사이에 미치는 것이 원칙이다.	
(2) 甲과 乙은 전소 당사자인바 전소 기판력 주관적 범위에 해당한다.	
4. 기판력 객관적 범위 및 작용국면 4	
(1) i) [제216조 1항] 오판시정 및 신속한 결론을 내리기 위해 기판력은 판결 주문 판단에 발생한다. ii) 전소 기판력은 후소에 동	

	일, 선결, 모순관계로 작용할 수 있다.
(2) 전후소 확인의 소의 소송물 동일 여부	
1)학설 i)구실체법설, 소송법설 불문 법률관계 공권적 확정을 통해 분쟁해결 구해 소송물은 실체법상 권리로 본다. ii)이지설 입장에서 소송물이론 일관해 청구원인으로 소송물 특정하는 견해 있다.	
2)判例 [법확전원다][중취상동]	
i)소유권확인판결 확정시 법률관계가 그대로 확정되어 변론종결 전 확인원인 되는 다른 사실이 있어도 기판력은 거기까지 미친다.	
ii)증여를 원인으로 소유권확인청구 했다가 소취하 후, 지분상속 원인으로 지분소유권확인 청구를 함은 동일한 소로 볼 수 없다.	
3)검토 및 사안	
i)생각건대 청구원인은 소유권 성질에 영향 주지 않아 다수설 타당하며, ii)사안에서 ①전소 기판력은 甲의 1/3지분 소유권 존재, 2/3지분 소유권 부존재에 발생한다. ②전소는 단독상속, 후소는 재산분할협의로 소유권 주장했으나, 법률관계 공권적 확정이라는 소유권 확인 특성상 이는 동일한바 전소 기판력이 후소에 동일관계로 작용할 수 있다.	
5. 기판력 시적범위 및 차단효 4	
(1) 원칙	
i)기판력은 전소 변론종결시 법률관계 판단에 발생한다. ii)전소 변론종결 전 제출가능했던 공격방어방법은 후소에서 차단된다.	
(2) 후소에서 차단되지 않는 변론종결 후 사유 의미	

	判例는 변론종결 후 사유란 새로운 사실관계를 말하는 것이고 기존 사실관계에 대한 새로운 증거자료, 새로운 법적 평가 또는 법적 평가가 담긴 다른 판결의 존재는 포함되지 않는다고 한다.
(3)	상속재산분할협의가 변론종결 후 사유인지 여부
	判例는 전소에서 원고가 단독상속인임을 주장해 소유권확인 구했으나 공동상속인에 해당한다는 이유로 상속분에 대해서만 청구인용판결 확정되었다면 전소 기판력은 변론종결 후 상속재산분할협의에 의해 소유권 취득한 나머지 상속분에 관한 소유권확인의 소에는 미치지 않는다고 한다.
(4)	사안
	甲이 전소에서 단독상속인임을 전제로 소유권확인 구하여 상속분에 대해서만 인용판결 받은 후 상속재산분할협의 이유로 소유권확인을 구하면 이는 변론종결 후 새로운 사유로 볼 수 있어 차단되지 않는다.
6.	사안해결 0.5
	전후소 소유권확인의 소는 소송물은 동일하나, 후소의 상속재산분할협의는 변론종결 후 새로운 사유인바 후소가 전소 기판력에 저촉된다고 본 판단은 부적법하다.
	[문제-4]
	I. 설문(1)
1.	문제의 소재 - 재심 의의 및 취지 [제451조] 1

	i)재심은 당사자 구제 및 법적 안정성의 조화를 위해 확정된 중
	국판결에 중대한 하자를 다투기 위한 제도이다. ii)허위진술에 기
	초한 확정판결에 재심사유 7호를 들어 재심 제기하는 경우 재심
	전속관할 및 이송에 따른 재심기간 준수 여부 검토한다.
2. 재심관할 법원 3	
(1) 원칙 [제453조 1항]	
	재심은 재심을 제기할 판결을 한 법원의 전속관할로 한다.
(2) 항소심의 사실인정을 이유로 재심 제기하는 경우	
1)상고심의 경우	
	재심사유 6호, 7호 등 사실인정을 재심사유로 재심 제기시 사실
	심 판결에 대한 재심사유는 될지언정 상고심판결에 대한 재심사
	유로 삼을 수 없다.
2)제1심의 경우 [제451조 3항]	
	항소심에서 본안판결 한 경우 제1심판결에 재심 제기 할 수 없다.
(3) 사안	
	항소심이 허위증언에 기초하여 본안판결했고 이런 사실인정을 이
	유로 재심 제기한바 항소심인 서울고등법원이 재심관할법원이다.
3. 재심관할 위반시 조치 4	
(1) 관할위반 이송 [제34조 1항]	
	법원은 소송 전일부에 관할권 없다고 인정시 결정으로 사건을 관
	할 법원에 이송한다.
(2) 判例	

1)상고심에 재심 제기한 경우 항소심에서 채택한 증거가 위조된 것	
이라고 주장하며 상고기각판결을 대상으로 재심의 소제기시 재심	
관할인 항소심으로 이송한다.	
2)제1심에 재심 제기한 경우 재심사유에 비추어 항소심 판결을 대	
상으로 제기한 것이면 항소심에 이송한다.	
(3) 학설 i)기간도과 불이익 구제 위해 1심법원 사이뿐만 아니라 재	
심관할법원 사이에도 제34조 이송 적용가능하다는 견해 ii)제34	
조 이송은 1심법원 사이에만 적용되고 재심관할에는 법적안정성	
을 이유로 적용하지 않는다는 견해가 있다.	
(4) 검토 및 사안	
i)생각건대 절차경제 위해 허용함이 타당하며 ii)사안에서 乙재	
심은 항소심 사실인정을 이유로 하는바 1심인 서울중앙지방법원	
에 제기시 제34조 1항으로 항소심인 서울고등법원으로 이송한다.	
4. 재심사유 7호 가벌행위의 경우 재심기간 준수 여부 2	
(1) 원칙	
재심사유 안날로부터 30일, 판결확정 후 5년내 제기해야 한다.	
(2) 가벌행위 재심사유	
재심사유 안날은 제451조 2항의 유죄확정판결이 있음을 안 때다.	
(3) 이송의 효과 - 소송계속의 이전 [제40조 1항]	
소제기 기간준수 여부는 이송한 법원에 소제기한 때로 판단한다.	
(4) 사안	
乙은 18.8.17.에 서울중앙지방법원에 재심 소제기한바 이 때를 기	

	준으로 재심기간 준수 판단한다. 乙은 유죄판결확정일인 18.7.24.
	로부터 1월 내인 18.8.17. 재심 제기한 것으로 취급되어 유죄확정
	판결 안 날부터 30일 내 소제기한 것으로 볼 수 있다.
5. 사안해결 0.5	
	서울중앙지방법원 이송 조치 적법하고, 서울고등법원 부당하다.
II. 설문(2)	
1. 문제의 소재 - 재심 의의 및 취지 [제451조] 0.5	
	i)재심은 당사자 구제 및 법적 안정성의 조화를 위해 확정된 중
	국판결에 중대한 하자 다투는 제도다. ii)대위소의 성질 및 재심
	의 당사자적격 관점에서 재심제기를 대위할 수 있는지 논한다.
2. 대위소 법적 성질 1.5	
(1) 학설 및 判例	
	i)고유대위권설은 민법이 채권자에게 인정한 고유의 대위권을
	제3채무자에게 행사한다고 보나 ii)判例인 법정소송담당설은 채
	권자가 채무자에 대한 권리 보전을 위해 채무자의 제3채무자에
	대한 권리 대신 행사하는 법정소송담당이라고 한다.
(2) 요건	
	피보전채권, 보전필요성, 채무자권리불행사는 소송요건이며 흠결
	시 당사자적격이 없어 대위소 부적법하다.
3. 재심의 당사자적격 3	
(1) 원칙	
	확정판결 당사자 또는 기판력 받는 자가 재심 당사자적격 갖는다.

(2) 判例

채권보전을 위해 대위행사가 필요한 경우 실체법상 권리뿐만 아니라 소송법상 권리에 대해서도 대위가 허용되나, 채무자의 제3채무자 사이의 소송이 계속된 이후의 소송수행과 관련한 개개의 소송행위는 그 권리의 행사를 소송당사자인 채무자 의사에 맡기는 것이 타당하므로 채권자대위가 허용될 수 없다.

4. 사안해결 0.5

채무자 乙은 이미 제3채무자 甲을 상대로 소를 제기하여 확정판결을 받아 권리행사한 이후이므로 재심의 소제기도 乙의 의사에 맡겨야 하고 채권자 丁은 乙을 대위해 재심 제기할 수 없다.

- 이 하 여 백 -